壹、总论

一、性質：无相对人之単独行為

1、不生法律效力⇒非法律上之遺囑 (ex：國父遺囑、蔣公遺囑，遺產記載兄弟和睦相处，不因遺產起衝突、張榮發，风吹雞蛋殼財去人安樂)

2、法律上遺囑 (ex：应继分指定)

3、§1165Ⅰ委託指定分割、§1209Ⅰ委託指定執行人⇒非委託契約之要約，仍屬単独行為⇒无需受託人承諾即生效力，受託人是否接受委託則任其自由 (通)

4、§1199死亡生效

5、§1189要式性

6、可变动性：可撤回

7、一身專屬性：§1186Ⅱ限制行為能力人有遺囑能力，不必法代同意

↳ §15-2Ⅰ⑥輔助宣告人应經輔助人同意，為遺囑不可補充性之例外

8、代執行性：須有独立執行机关，任執行遺囑之執務

二、內容：以財產相关為原則，身分相关為例外

1、与財產相关：

(1) 遺贈 (§1200~1208)

(2) 应继分指定 (§1187)

(3) 遺產分割方式之指定或指定之委託 (§1165Ⅰ)

(4) 遺產分割之禁止 (§1165Ⅱ)

(5) 遺產執行人之指定或指定之委託 (§1209)

(6) 遺囑之撤回 (§1219)

(7) 捐助行為 (§60)

(8) 信託行為 (信託§2)

(9) 領受撫卹金遺族之指定 (公務人員退休資遣撫卹法§63Ⅱ本文、公立學校教職員退休資遣撫卹條例§63Ⅱ本文)

2、与身分相关

(1) 監护人之指定 (§1093)

(2) 认領行為若认有效則可按§1069溯及子女出生時

3、內容未違強制規定或公序良俗均应肯认其效力，不以法有明文者為限 (通、5c18上2715例)

三、遺囑能力

1、不因遺囑內容有无关於財產而異其标準，採劃一主义。有认為此時应以识别能力為断，但实務上举証不易

2、无行為能力人

(1) JP§973Ⅰ医師二人以上於回復常態時証明，亦得為遺囑

(2) 通：受監護人於回復常態亦不得為遺囑

(3) 鼎：立法論上有置疑餘地/環：立法論上如能証明立遺囑時確為回復原狀，具识别能力，不妨其自為遺囑

(4) 經監護宣告但无意识或精神混乱中→§75後 无效，已聲請未宣告時之所為應視其為遺囑是否於常態中

3、未滿16歲之限制行為能力人（§1086Ⅱ但：不得為遺囑）：縱有法代允許，遺囑仍為无效（§71）

4、決定遺囑能力之時期：作成遺囑時（台中高分院102家上98：主張无遺囑能力方負举証責任（民訴§277））

5、§15-2Ⅰ⑥輔助宣告人應經輔助人同意，為遺囑不可補充性之例外

四、共同遺囑：2人以上依同一証書作成之遺囑

(1)种類（FR、Ger 14~15century）

A.单純共同遺囑：各自独立二遺囑记載於同一份遺囑書中（ex：甲贈A予乙，丙贈B予丁）

B.相互共同遺囑：相互為遺贈或相互指定他方為自己继承人（ex：甲遺贈乙A，乙遺贈甲B）

C.相关共同遺囑：相互以他方之遺囑為條件之遺囑，一方失效他方亦失效，一方遺囑執行後，他方不得再撤回

D.其他（ex：二遺囑人共立遺囑將共同財產遺贈他人）

(2)效力

A、Ger §2265~2273：夫妻間得為共同遺囑

B、FR§968、JP§975 明文禁止

C、否定說（通）：雖无禁止明文，既採遺囑撤回自由原則→凡有礙之撤回自由者，如未經明文认許，解釋上應全在禁止之列，且易生疑义，无肯定必要

D、肯定单純共同遺囑說（史）：內容完全独立，應无須禁止

E、書寫方有效說（林）：甲書寫內容，甲乙簽名，乙因未書寫全文，不符自書遺囑要件无效（§1190），甲則應认有效

貳、方式一：自書遺囑（§1189①）

一、总說：簡单，費用低，秘密性高；易違要式性，无見証人故易受偽造及变造

二、方式（SC28上2293例：未依規定方式无效）（§1190）

1、自書遺囑全文

(1) 自行書寫：以確定係本人筆跡→打字、影印机影本自不屬之，不识字之人自无從為之（SC102台上900裁、85台上2142）

(2) 他人協助書寫亦可能有效，惟經鑑定筆跡非遺囑人時，則非自書遺囑

2、记明年月日：判斷立遺囑時有无遺囑能力，二遺囑牴觸以日期定其先後

(1) 可得確定即可（ex：115年中秋、結婚30年紀念日）（通）

(2) 记完成日期，若完成日早於所載日以记載為準（通）

(3) 过失记載非完成日若可推斷遺囑人有记明真实日期之意思表示時應认仍有效（通）

(4) SC102台上1192：先影印內容後簽名及寫上年月日→无效

(5) SC108台上444：公証人註记日期非遺囑之一部，故无從補正日期，遺囑无效

3、親自簽名

(1) 位置不定，不限本名，可資识别即可

(2) 蓋章代替

A、肯定说（環、戴）：§3Ⅱ已明文

B、否定说（通）：目的係防止偽造或變造 ⇒ 蓋章无從比对，解釋上应排除§3

(3) 增減塗改（§1190後）：注明增減塗改处所与字数，另行簽名

A、通：未依方式变更視為无变更（SC 91台上1260、103台上2397裁、95台上840裁、法務部(80)法律16232号函、司法院(77)秘台厅(一)01337号函）

B、SC 97台上2642：塗改过多且皆未另行簽名无效

參、方式二：公証遺囑（§1189②）

一、总说：内容真实，証据力強，不因方式不備无效，惟因有見証人較无隱密性

二、方式（§1191Ⅰ）

1、指定2人以上見証人

(1) 由遺囑人指定見証人，其任務係証明遺囑之真正、監督公証執行其职務

(2) 見証人应自遺囑人口述开始起，至全部完成時全程在場，提前離去視同无見証

(3) 至少2人，適格人数<2則遺囑无效

2、遺囑人於公証人前口述遺囑意旨

(1) 口述：口頭陳述，不得以點頭或手語 ⇒ 啞者无法為公証遺囑，並不得由見証人轉述

↳ 聾者若曾受發音训練而能為口頭表述時自得為之

(2) 外國人得於TW為公証遺囑，經請求得以外國文字為之（公証§5Ⅰ但）

(3) 遺囑以中国文字作成而遺囑人不通中國語言者，則公証人作成公証遺囑時应由通譯傳譯（公証§74）

(4) 遺囑人自書後交与公証人，公証人据以作成遺囑

A、否定说（環、戴、棋、林）：不符形式，不可称之口述，自属无效

B、肯定说（史、振）：TW民法以見証人能証明其遺囑出於真意即為已足，筆记内容是否与口述結合无須見証人认可，自应认可

C、通：先筆记再口述应认有效

3、公証人筆记、宣讀、講解：使遺囑人確认遺囑之意思，对文盲或盲人甚為重要，但閱讀代替宣讀？

(1) 否定说（胡、鼎、范揚、戴炎輝）：明文，閱覽自不符合之，聾者自不得依此方式因无從明瞭

(2) 肯定说（棋、史、林）：公証§84Ⅰ可任選其中一种方式，閱覽对聾者尤具意义，惟聾者又不识字者自无從為公証遺囑

4、遺囑人认可：不认可時公証人应予以更正並重行講解後再經认可

5、公証人记明年月日，公証人、見証人、遺囑人須簽名，簽名与日期顛倒亦无不可

6、§1191Ⅰ後：遺囑人不能為簽名，得按指印代之，但公証人应將事由載明 ⇒ §3Ⅲ符号代簽名，公証遺囑僅能依指印代之，見証人之簽名不得依指印代之

三、公証人職務之代行（§1191Ⅱ）

1、无公証人之地，由書記官行之，僑民於ROC領事駐在地為遺囑時得由領事行之

2、於非ROC之領事之公証遺囑，其遺囑无效 ⇒ 符合代筆遺囑方式仍可轉換為有效之代筆遺囑（§112）（楊、林）

四、公証費用（公証§109）

肆、方式三：密封遺囑（§1189③）

一、總論：有見証人及公証人証明，內容又可保守秘密，兼自書及公証遺囑之所長，惟易變造及違反要式性

二、方式

1、遺囑人簽名：內容无人知，且无須本人親自書寫，故要求簽名

(1)不能簽名无法為密封遺囑

(2)无須記明日期，即使記明亦非以記明之日期為遺囑成立之日

(3)內容增減

A、類推§1190後說（史、楊、戴）：注明增減塗改處所及字數另行簽名

B、无須作為說（林）：密封遺囑得由他人代筆，要求代筆人簽名无太大意义，且多此一舉，因已密封，无刪除、塗改之可能

2、密封並於封縫處簽名

(1)密封人

A、限遺囑人說（通）：條文文义觀之

B、不限遺囑人說（史、楊）：於其面前命他人為之亦无不可

(2)密封方法：不限，只要不使內容外洩即可（林、劉含章）

3、遺囑人指定二人以上見証人向公証人提出，陳述係自己之遺囑，如非本人所寫，並應陳述繕寫人之姓名、住所

(1)見証人僅對遺囑人向公証人提出、向公証人所為陳述及公証人於封面所為之記明見証，遺囑內容見証人无從知悉自无從見証

(2)公証人僅對遺囑提出之年月日及遺囑人所為陳述負記明之責（劉含章）

(3)代人代寫之顯名以便日後有所爭執時訊問代筆之人

(4)陳述內容僅須說明係自己之遺囑即可，无須涉遺囑內容

(5)陳述不限口述，封面上載明係自己之遺囑亦可 ⇒ 啞人亦得為密封遺囑

4、公証人於遺囑封面記明遺囑提出之日期及遺囑人所為之陳述

(1)不得記明於其他紙

(2)遺囑能力之有无及成立之先後均以公証人記明之年月日為準

5、公証人、遺囑人、見証人同行簽名 ⇒ 遺囑人簽3次名：遺囑書 ⟶ 封縫處 ⟶ 封面

三、向公証人提出 ⇒ 準用§1192Ⅱ 公証人職務之代行

四、§1193 不符密封遺囑形式而具自書遺囑方式者有自書遺囑效力（林：此屬注意規定，非繼承法上特別規定，縱无此條，仍可由§112轉換）

五、公証費用：1000元（公証§117）

伍、方式四：代筆遺嘱（§1189④）

一、总論：文盲无法書寫者，節省費用，簡易便行，惟非公证人作成，可能影响遺嘱人意思

二、方式（§1194）

1、遺嘱人指定3人以上見证人：3人中有1人為代筆人，实質上亦屬2見证人

2、遺嘱人口述遺嘱意旨：同公证遺嘱

3、見证人中一人筆记、宣讀、講解：代筆人須為見证人中一人（台中高分院101家上17：三行為缺一不可）

(1) 打字

A、否定说（通）：須親自動筆，不得打字代之

B、肯定说（SC 86台上432）：未規定筆记方式，起稿送打亦无不合

(2) 不同人講解、筆记

A、肯定说＝不限制说（105.4.16第5次民庭決议）：三行為各自分立，各有作用及目的，非一行為，避免增加法律所无之限制

B、否定说＝限制说：若採前说則條文不必记載由見证人中之一人，且既无公证人，对程序之要求應不少於公证遺嘱

4、經遺嘱人认可後，记明年月日及代筆人簽名：大致同公证遺嘱

5、見证人全体及遺嘱人同行簽名，遺嘱人不能簽名者應按指印代之

(1) 見证人全体應包括代筆人在內（通），惟此屬多此一举，代筆人既已遺嘱簽名，已生效力

(2) 无須记名不能簽名之事由，惟仍不得以蓋章代之

陸、方式五：口授遺嘱（§1189⑤）（实務上少見）

一、总说：此係特殊方式，方式簡单，民74增订錄音口授遺嘱，惟倉促可能難確保当事人爭议

二、前提要件（§1195本文）

1、生命危急或其他特殊情形

(1) 生命危急

A、主观说（史）：遺嘱人主观判斷，无須客观认定（批評：憑空想像難认危急）

B、主客观兼備说（楨）：有死期將近之客观事实，主观上亦自覺死期將近（批評：緩不濟急）

C、個案審查说（林）：綜合外在客观情状是否皆為一般人可合理預期之客观狀態

(2) 特殊情形：交通斷絕（天災、罷工、暴动、传染病）、戰爭

2、不能依其他方式為遺嘱

三、筆记口授遺嘱之方式（§1195①）

1、遺嘱人指定2人以上見证人：一人筆记，一人監督

(1) 史、楨：聾啞、盲及不能簽名者均不得為見证人

(2) 林：應僅聾及不能簽名者不得為見证人，因口述遺嘱无須宣讀、講解

2、遺囑人口述遺囑意旨；同代筆遺囑

3、見證人中一人將該遺囑意旨作成筆記⇒易遭竄改，為求慎重，若有竄改應類推§1190後，否則竄改無效，原筆記仍有其效力（史、戴、林）

4、筆記人記明年月日，與其他見證人同行簽名⇒無須遺囑人簽名⇒易偽造（通）

(1) 環：見證人之簽名應於遺囑人生存中為之，若簽名於死後則要件不備

(2) 史、戴、林：死亡後經見證人簽名證明為正確後仍有效成立

四、錄音口授之方式（§1195②）

1、遺囑人指定2人以上見證人

(1)須聽取口述之意旨⇒聾者無法任之

(2)須全體口述遺囑之為真正及見證人姓名⇒啞者無法任之

(3)須於封縫處簽名⇒不能簽名者無法任之

2、遺囑人向全體見證人口述遺囑意旨、遺囑人姓名及年月日，全部予以錄音⇒遺囑無須簽名

3、見證人全體口述遺囑之為真正及見證人姓名，全部予以錄音；應見證人一一輪流口述，因同時口述無法辨識，失其立法目的

4、將錄音帶當場密封並記明年月日由見證人全體於封縫處同行簽名；防止竄改，全體簽名表示係遺囑人所立無誤

↳錄音帶、錄影帶、錄音筆或留聲片有錄音者均可（通）

五、有效期間（§1196）：遺囑人能依其他方式為遺囑時起，經3月失其效力

1、ex：危急狀態解除、精神已健全能自書遺囑、交通已回復

2、特殊情形解除後未滿3月又發生，應自第二障礙消除之日起算

六、認定（§1197）：應由見證人中一人或利害關係人，於遺囑人死亡後三月內提經親屬會議認定真偽，如對認定有異議得聲請法院判定之

1、請求權人

(1) 見證人：不問何者皆可

(2) 利害關係人：繼承人、受遺贈人、同一遺囑人之他遺囑受遺贈人、遺囑執行人、遺產債權人？

A、肯定說（胡、范揚）

B、否定說（史、戴、林）：債權人僅就知悉自己債權有無得受滿足之程度之遺產，有其利益，債權優先於遺贈故遺囑不影響債權人權益

2、認定人：親屬會議，有§1132Ⅱ適用，提經親屬會議認定不得拒絕

3、對象：本應屬有效之遺囑，無效之遺囑縱經認定仍屬無效，認定後仍得對效力爭訟

(1) 親屬會議成員法學知識有限⇒僅就遺囑真偽認定即可⇒遺囑要式性判斷非其職務，惟含形式及實質真偽（ex：無事實之捏造－形式
非當日所為－形式
記載與意旨相反事實－實質）

(2) 法院若發現為不符形式之遺囑，於受領聲請時應可駁回其聲請⇒若予認定待執行後再爭執將不安定及損害法院權威，有害無益（林）

4、期限：遺囑人死後3月內（林：應由法院，親屬會議組成不易且法條細節常人未注意，有待檢討，若交通不便或航海，三月無意義，不如得由長官或船長認定）

5、調查：獲取心證，得詢問當時狀態、作成經過，並注意見證人平日操守社經地位，有無偽、變造可能

6、執行前之提示
- 需要說（通）
- 不必要說（林）：TW提示與JP檢證不同，僅具提出意義，既已認定則有提示意義，再為提示實乃多此一舉

7、異議：§1137 3月內為之，此異議之係含撤銷認定及請求確認遺囑真偽之雙重意義

柒、見証人之法定消極資格（§1198）（實務常用爭點）

①未成年人，已結婚（舊法爭點）？

1、否定說（劉含章、戴、林）：明文訂之應採嚴格解釋＋26院1628雖對遺囑執行人作解釋，亦可作參考，且繼承編對未成年之定义皆含已結婚者 §974、981、1049但、1076-2、1080Ⅲ、1080-1Ⅲ、1210

2、肯定說（史、棋）：有行為能力亦應有見証人能力

②受監护或監护或輔助宣告之人：縱正常狀態下亦不得任之

③繼承人及其配偶或其直系血親

④受遺贈人及其直系血親

> 禁止有利害关係之人，維护遺囑之真实 ⇒ 直血：不含收養後之本生父母（SC109台上95）

↳无利害关係（SC20上2305例：已无繼承权）

⑤為公証人或代行公証職務人之同居人、助理人或受僱人：限公証与密封遺囑 ⇒ 对公証人有

⑥缺格者參与若除去計算後仍達法定人數則仍有效

⑦代筆遺囑之代筆人或筆記口述遺囑之筆記人缺格，惟見証人人數已達標

1、无效說（劉含章、羅鼎、戴、林）：代筆人缺格 ⇒ 无人代筆，不符要件无效

2、有效說（棋）：无需做区別，見証人人數已達標準，要件已備

捌、撤回

一、撤銷

1、~74：撤銷 ⇒ 使已生效之法律行為溯及歸於无效 ⇒ 74~修正為撤回

2、詐欺脅迫得撤銷，惟一身專屬之撤銷於喪失意思能力時遺囑人將无從撤回 ⇒ 應认例外（通、JP通）

(1) 生前未撤銷而死亡 ⇒ 撤銷权得繼承

(2) 撤銷之標的非已生效之遺囑，而係遺囑人所為之意思表示

二、方式

1、明示撤回（§1219）

(1) 要式性：依遺囑方式為之，不必与被撤回之遺囑同一方式為之

(2) 撤回权人 ⇒ 若宣告护則无法撤回

(3) 時期：前遺囑成立後至生效前

(4) 範圍：全部或一部

2、法定撤回

(1) 前後遺囑相牴觸（§1220）：後遺囑優先原則

A. 牴觸：互不相容

(A) 主觀說（胡）：以遺囑人主觀意思以為決定，外觀如何在所不問 ⇒ 外觀上相似而非不能相容者應併存之（ex：A贈甲，A贈乙，认為有使甲乙共有A之意思）

(B) 限制主觀說（史棋）：先後遺贈除遺囑明示外均應視前遺贈為撤回

(C) 客觀說（林、通）：判斷主觀意思於死後極為困難，為免多餘爭執，法律擬制撤回 ⇒ 无視外觀之牴觸是否不符立法目的

B、不能分先後：无同时成立可能，惟日期相同无法判断 法未明文

(A)有效说（胡、戴）：各遺嘱有效，執行其一，对他遺嘱以補償方法為救濟

(B)无效说（棋）：視同矛盾，牴触部分均无效

(C)類推Austria §715说（林）：无相類規定故可引入外國立法例為法理 ⇒ 可同时併存者皆有效，競合則準用共有之規定 ⇒ 共有受遺贈权

(2)前遺嘱与後行為相牴触（§1221）

A、遺嘱人所為之行為

(A)行為

a、廣义说（林、劉含章）：不論法律、事实行為，因未明文規定 ⇒ 含死因贈与与死後处分行為

b、狭义说（通）：參考JP§1032Ⅱ ⇒ 限生前法律行為

(B)遺嘱人親自為之 ⇒ 因強執歸屬第三人不屬之，惟有§1202 遺贈物非遺產遺贈无效

(C)16岁个，未得法代同意 所為牴触遺嘱之行為

a、撤回说（棋、振）：无須法代同意即得独立為遺嘱 ⇒ 未同意之行為亦应可生撤回效力

b、不撤回说（史、林）：依 Swiss民法，須生前处分行為有效始生撤回效力且因要式性故可以後行為有效係為遺嘱撤回之前提

B、牴触

(A)行為時声明无撤回意思

a、不生撤回效力说（史、棋）：惟財產不屬遺產者应仍有§1202但適用

b、生撤回效力说（林、范揚、琛、鼎）：其表示本即矛盾，且§1221係擬制非推定亦无例外規定，无從推翻擬制

(B)附始期之後行為（§102Ⅰ）

a、期限於生前屆至：§1221 法定撤回

b、期限於生前未屆至：行為未生效 ⇒ 未撤回 ⇒ §1199 遺嘱生效，生效遺嘱无從被撤回，标的物不当然歸屬後行為之附始期受贈人

(C)附終期之後行為（§102Ⅱ）

a、期限於生前屆至：按撤回之立法意旨係避免判斷意思及執行困難 ⇒ 无執行上困難又不難推知无撤回意思无將遺嘱視為无效之必要

b、期限於生前未屆至：§1221 法定撤回 ⇒ 遺贈不生效力，亦不会回復效力

(D)附停止條件之後行為（§99Ⅰ）：同附始期之後行為

(E)附解除條件之後行為（§99Ⅱ）：同附終期之後行為

(3)遺嘱之廢棄（§1222）= 物質撤回：屬明示撤回中之一种方便或例外做法

A、遺嘱人有破毀或廢棄之故意：故意指遺嘱人认识其為遺嘱，不問其真意（通）⇒ 应由遺嘱人親自為之，第三人擅為之不生效力

B、可令第三人代為破坏或塗銷：須於第三人生存期間為之，不問记載人惟須证明係出於遺嘱人意思，受監宣後破毀、塗銷不生撤回效力

C、破毀：有形毀掉遺嘱書之一切行為 ⇒ 含焚燬、撕碎、裁断、切去一部，遺嘱含錄音口授遺嘱 ⇒ 洗去錄音亦屬破毀

D、廢棄：客觀上有撤回意思即為已足，遺嘱上指遺嘱書本 ⇒ 密封遺嘱之封面记載无效

E、公证遺嘱之原本於公证处，原本之廢棄或破毀不生撤回效力 ⇒ 公证程序撤回 1000元（公证§114）

三、撤回之撤回：TW未明文，亦有二种立法例

1、復活主义说（Ger §2257、2258Ⅱ、史）：死亡後真意難推求，原则应推定制有意回復原遺囑，惟仍应实際考量係明示撤回或法定撤回

2、不復活主义说（JP §1025）：撤回後原遺囑已為自始不存在，撤回之撤回不復活，且縱有復活之意，亦大可再立一份

3、例外依明示真意復活说（棋、琛、胡、振）：同前，惟明確表示時則承认之，因已无争议性且尊重遺囑人意思

4、針对法定撤回之撤回採不復活主义（FR §1037、1038）

5、個案审查说（鼎、戴、林、JP通）：此屬立法主义之選擇，实定法上若无根据，解釋上仍以個案具体事实斟酌遺囑人判斷之

(1) 以第二遺囑明示 §1219 撤回第一遺囑後再將第二遺囑撤回

- A、以第三遺囑明示 §1219 撤回第二遺囑：通常可认有使第一遺囑復活之意，且第二遺囑經撤回自始不存在，不生牴触問題（史、范揚、戴、棋、林）
- B、再為第三遺囑 §1220：非撤回之撤回，因二与三遺囑未牴触⇒第一遺囑无從復活
- C、自為生前行為 §1221：非撤回之撤回，因二遺囑与行為未牴触⇒第一遺囑无從復活
- D、故意廢棄第二遺囑 §1222：第二遺囑經撤回自始不存在，通常可认有使第一遺囑復活之意（史、戴、林）
- E、二遺囑欠缺法定方式无效：自始不生撤回效力⇒非撤回之撤回，一遺囑自始有效

(2) 第一遺囑因牴触二遺囑而被視為撤回 §1220，第二遺囑受撤回

- A、以第三遺囑明示 §1219 撤回第二遺囑
  - (A) 戴、棋、JP学说：遺囑人无使第一遺囑復活之意
  - (B) 林：第二遺囑經撤回自始不存在⇒第一遺囑无牴触問題則未被法定撤回，自然因此復活
- B、故意廢棄 §1222 二遺囑：同上
- C、三遺囑牴触 §1220 二遺囑而二遺囑視為撤回
  - (A) 史：不能斷定有无使一遺囑復活之意，應解為一遺囑因牴触之除去而復活
  - (B) 戴、林：三遺囑与一、二遺囑內容不同，自应以三遺囑有效，一二遺囑无從復活
- D、生前行為与二遺囑牴触：一遺囑与所為行為相互牴触，可认无使一遺囑復活之意⇒无從復活

(3) 行為 §1221 牴触二遺囑，行為受撤銷或无效

- A、不復活说（棋、戴）：通常可认有復活意思，僅部分原因使積極意思未得实現而已，消極之意思仍存在
- B、復活说（史、戴東雄變更後見解、林）：§114自始无效＝根本无生前行為可言，§1221之行為应以有效為前提，作欺脅迫亦如此，且非屬撤回之撤回
- C、折衷说（范揚）：受作欺脅迫非出於本意⇒一遺囑復活，否則原則不復活

(4) 廢棄遺囑又使之回復原狀

- A、戴、棋：廢棄之撤回屬事实行為，不得為撤回或視為撤回之標的⇒不生再撤回、无效等問題
- B、林：塗銷不限方式⇒鉛筆塗銷又擦拭乾淨回復原狀可推知復活意思

(5) 第一遺囑因牴触二遺囑而被視為撤回，二遺囑之受遺贈人先遺囑人死亡：為二遺囑時无法預知先死亡⇒可推知无使一遺囑復活之意

(6) 第一遺囑因牴触二遺囑而被視為撤回，二遺囑附停止條件而條件成就前或確定未成就後受遺贈人死亡：未成就⇒不生撤回效力⇒一遺囑自始未撤回⇒不生復活問題

(7) 第一遺囑因牴触二遺囑而被視為撤回，二遺囑附解除條件而遺囑人死前條件成就
- 不復活说（棋、戴）：通常不可认有使一遺囑復活之意
- 復活说（林）：解除條件⇒不能撤回一遺囑⇒撤回繫於條件⇒不生復活問題

玖、執行

一、執行必要

1、不須執行：§1187、1165Ⅰ、Ⅱ、1209、1219、1093

2、須執行始達目的者：§60、62、1200～1208、信託§2

3、以遺囑為认領

(1) 肯定說（舊戶籍法、史、林）：子女以公示於戶籍簿上為其利益，委以与子女利益相反之繼承人此声請，甚為危險，故舊法明文之

(2) 否定說（林、戴）：新法下认領自寫下即生效力，溯及子女出生時→不必執行

二、準備程序

1、交付与通知（§1212）

(1) 提示之目的（～103§1212）

A、確认形式防偽說（通）：確认狀態，防止事後偽、變造，並妥善保存

B、單純知悉說（劉鍾英、胡、鼎、劉含章、林）：不过使親屬会议知其存在及內容而已，无JP§1004勘驗程序性質

(2) 提示僅為準備程序，非生效要件，未經提示不影响效力（通、SC 22上1855例）

(3) §1212已知之繼承人應參考§1177繼承人有无不明之解釋→從寬认定，戶籍上記載或其他客觀情事认定

(4) 义務人：遺囑保管人、繼承人

A、遺囑保管人：含受託保管人及事实上保管人

B、无保管人由遺囑人自行保管，死後繼承人發現，交付予執行人

C、无保管人且發現人非繼承人：類推§1212交付執行人，不知有无執行人者通知已知之繼承人

D、封緘之遺囑：通知即可

E、无遺囑執行人→仍須§1211親屬会议選定→林：修正之目的不達，仍須召开親屬会议，單一條文之片段修正意义不大

2、开視（§1213）：非於親屬会议当場或法院公证处

(1) 自書遺囑、代筆遺囑亦可封緘，惟封縫處无須簽名

(2) §1213Ⅱ开視紀錄記明封緘有无毀損或其他特別情事，並同在場之人同行簽名

(3) 不限何人為之→开視仍由保管人或繼承人為之，公证处及親屬会议僅為认证（公证§2）並負責製作紀錄而已

(4) 係準備程序，非生效要件，違反之遺囑仍有效（通）

三、執行人

1、產生（§1209、1211）：依下列順序

(1) §1209Ⅰ遺囑自行指定或委託他人代為指定

A、委託繼承人或受遺贈人

(A) 否定說（史）：執行遺囑所生法律关係之当事人不含受託人，故繼承人与受遺贈人不得受指定

(B) 部分否定说(胡)：繼承人与遺囑之執行有重大利害关係，解釋上不能為受任人，惟受遺贈得為受任人

(C) 肯定说(通)：尊重遺囑人之信任，法無限制則任何人皆可任之，且文義解釋上他人指遺囑人外之人，不同於無利害关係之第三人

B、受任人得拒絕就職

(A) 向親屬会议表示说(戴、棋)：依法应由親屬会议另行選定 → 应向親屬会议表示

(B) 向繼承人表示说(通、振)：親屬会议非常設机关，向其表示極困難 + §1215Ⅱ、1216，故应向繼承人表示再由繼承人召开親屬会议

C、不表示時，得催告期限內確答，逾期未確答視為拒絕

D、§1209Ⅱ：受任者应即指定執行人並通知繼承人

(2) §1211前 親屬会议選定 → 爭議是否必為選定執行人

A、否定说(琛、林)：有自由裁量权，故明文「得」指定，縱有必要而不為指定時無從強制非選定不可，僅利害关係人得聲請法院指定之

B、肯定说(戴)：「得」应解為有权限之意，与§1211後相同 → 非可不予選定之意

C、遺囑外觀上顯無效者得不為選任说(棋)：須具備選定遺囑執行人之要件

(3) §1211後 法院指定

A、須§1211前親屬会议不能指定，不得逕為聲請(劉含章、林) → 不能含事實上或法律上不能，消極不選定為其事實上便利，亦屬不能

B、利害关係人：繼承人、遺產債权人、受遺贈人、受遺贈人之債权人

C、法院：家事§127Ⅰ⑥ 繼承开始時被繼承人住所地專屬管轄，聲請後進入非訟程序，法院得駁回，利害关係人得对裁定抗告

D、§60Ⅲ 捐助行為排除§1211，主管机关、檢察官

2、消極資格限制(§1210)：未成年人、受監护或輔助宣告之人不得為執行人

(1) 繼承人(§1198：不得為見證人)

A、否定说(胡)：繼承人对遺囑有重大利害关係 → 受遺贈人之利害將受繼承人左右

B、肯定说(通、35院解3120)：§1210未排除，且尊重遺囑人，無法妥当執行時自有解任方法

(2) 未成年人不論結婚与否(通、26院解1628)

3、法律地位(§1215Ⅱ)：視為繼承人之代理

(1) 被繼承人之代理人说(戴)：執行人=遺囑人時係文不合理，就特別事項於必要範圍內承认死者法人格之存續应無不可

(2) 繼承人之代理人说(通)

A、人格承繼说(史)：係實質上遺囑人能力之一部，死後存續，然於法律構成上假託於承繼遺囑人地位之繼承人

B、實際需要说
破產管理人比照说 (鼎、胡、范揚)：兼顧繼承人与遺囑受益人之利益 → 与破產管理人相似，遺產本即歸屬繼承人，代理係為實際之故

C、文义拘束说(棋、50台上2361例)：雖常立於对立地位，惟於實定法解釋上無法忽視明文規定，不得不從繼承人代理人说

(3) 爭論無益说(林、鈴木祿彌)：前说主觀上無代理意思，客觀上未踐行顯名主义，且常有利害对立致訴訟地位矛盾
应认§1215Ⅱ立法意旨不在賦予代理人地位，而僅於執行職務行為之法效果上，擬制及於繼承人而已

4、職務与权限

(1) §1214 編製遺產清冊交付繼承人，被繼承人或繼承人免除？

A、不得免除说（通）：性質上有关公益，被繼承人与繼承人均不得免除

B、得免除说（林）：与公益无关，主要在於保护繼承人之利益，繼承人认无必要或避免支付編製費用，得免除之
§1150 遺產支付之

(2) §1215Ⅰ管理遺產：限与遺囑有关之財產，与遺囑无关之遺產仍由繼承人管理

(3) 執行上必要行為

A、遺贈物之交付

(A) 交付遺贈属处分行為，而遺贈僅具債权效 ⇒ 土登規則§123Ⅰ 繼承人先登记再会同受遺贈人辦理所有权移転登记

(B) 遺贈物不特定或為金錢 ⇒ 為取得必要時，对全部遺產有管理处分权 ⇒ 变賣遺產必要時得為之

B、訴讼行為：第三人占有時執行人得以自己名义起訴請求返还，受遺贈人提履行遺贈义務之诉亦僅得以執行人為被告

C、§61Ⅱ 向主管机关声請設立財团之许可後移転，設立登记非其職務权限

D、信託§46 先催告受託人是否受託，拒絕則得以利害关係人身分声請法院選任受託人並將財產移転之

E、§1216 繼承人妨害之排除 ⇒ 僅於有執行人時有其適用

(A) 執行職務中：注意規定 ⇒ 应解為自繼承开始時，无論有无執行人，其当然不得為与遺囑相关遺產之处分行為

(B) 处分：含法律及事实上处分

(C) 亦不得妨礙其職務之執行 ⇒ 執行人以繼承人為被告起訴

(D) 繼承人处分效力

a、絕对无效说（劉鍾英、鼎、琛、范揚）：§1216係強制規定，§71无效

b、效力未定说（史、棋、戴、林）：无权处分，处分对遺囑实現有利或未生衝突，无須逕认无效

(a) 不特定遺贈：繼承人对全部遺產无处分权，若对執行不足妨礙，不必使其受阻礙，執行人得同意或承认

(b) 特定物遺贈：同意处分标的物將与遺囑人意旨相違 ⇒ 应属无效（林）

(c) 繼承人為執行人：处分特定物遺贈仍属有效，但对受遺贈人应負債務不履行之損賠責任（林）（§226Ⅰ/544）

(4) 執行人与遺產管理人之職務分配：无人繼承時，§1179可能致权限重疊 ⇒ 併存形成混乱，应由下列順序（通、SC 85台上684、90台上314、91台上786、97台上554、99台上1588）

A、遺產管理人先行清算及搜索：此期間內執行人权限停止，且立法上執行人不排除管理人 ⇒ 執行人兼管理僅為便利，若有管理人則回歸本职之執行工作

B、執行人執行遺囑：執行人於有管理人之情形僅負責執行

C、管理人行最後清算程序：未於公示催告期間為報明債权或声明之受遺贈人对其清償或交付遺贈物後歸於國庫

5、方法（§1217：数人執行職務以过半数决之，但遺囑另有意思表示者從其意思）⇒ 二人可否同数？

(1) 解任说（棋）：類推§1218 利害关係人請求或声請解任其中一人而改選他人

(2) 增加員額说（林）：此非重大事由，難適用§1218 ⇒ 亦应避开偶数且解任何人甚難决定 ⇒ 類推§1211 增加一人

6、報酬請求权（104 ~§1211-1）（戴：修法前採否定说）

7、注意义務：善良管理人（林、史）⇒ 執行人与管理人有诸多相似之处 ⇒ 应与管理人之通说相同标準

↳ 戴：不得請求報酬 ⇒ 執行職務应以具体輕过失（无償委任）／棋：应視有无報酬而定（折衷说）

8、解任（§1218）

(1) 怠行職務：对§1214、§1215Ⅰ所定職務不為積極履行

(2) 其他重大事由：无論可否歸責執行人（ex：入監、長期去向不明、重大疾病）

(3) 監护或輔助宣告：不待解任即因§1210当然失格，此时利害关係人亦得请求或声請改選

9、辞任：法无明文 ⇒ 通：肯定，惟有无限制？

(1) 须正当理由說（通）：依JP ⇒ 有正当理由始可許其辞任

(2) 无限制說（史、棋、林）：舊法（~97）公益性質之指定監护人无须§1095正当理由，舉重明輕，且執行人非不可或缺，因无執行人时得由繼承人為之

拾、遺体及喪葬

一、遺囑指定喪葬：无效，因§1187限处分「遺產」，喪葬非遺產 ⇒ 无殯葬自主权（通）

二、遺体

(1) 為物（通、実、96台上2109）：繼承人依公同共有方式处分之，僅所有权內涵限埋葬、管理、祭祀，不得自由使用、收益、处分，遺体受不法占有得请求返还

A、屬遺產說（通）：繼承人有埋葬屍体之权利义務

B、非遺產說（胡）：屍体非民法上所謂之物 ⇒ 非繼承之标的 ⇒ 繼承人原始取得而公同共有，亦无法由遺囑決定喪葬方式

(2) 非物（戴瑀如）

A、非遺產故无法遺囑決定喪葬方式

B、由人格权延伸至自主決定权方式处理，尊重死者生前意願（戴瑀如）

三、生前簽訂自用型生前殯葬服務契約

1、黃詩淳

A、僅具債权效：通认死者无遺体处分权 ⇒ 无法將遺体移転予业者

B、业者僅得根據契約对繼承生前契約債权之繼承人请求移転遺体

C、立法論上应承认死者有遺体处分权，並得指定遺体处分权人使其取得物权性权利

2、戴瑀如

A、应以身後事之決定权（人格权）取代遺体处分权

B、參照安寧緩和條例、人体器官移植條例 ⇒ 本人生前对人身事項有決定权

C、殯葬管理條例§61Ⅲ：应予尊重 ⇒ 应强化本人意願之地位

D、Ger：若本人未有事先表明意見，配偶或最近親屬因了解本人意願而有优先決定权

E、立法論上应參考医療決定权人順位，若同順位中数人有爭執引進法院判斷何者最合乎本人意願，以尊重個人自主決定权